

1512530-70.2021.8.26.0019

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/02/2022

... municipais, que tinham o local como ponto de tráfico, receberam denúncia de tráfico, descrevendo ao réu e o endereço onde poderia ser localizado.

O réu, ao visualizar a viatura e suspeitar que seria abordado, jogou os entorpecentes ao solo (18 pinos de cocaína), com fim de se eximir de sua propriedade e responsabilidade. Revistado, com ele foi localizada a importância de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

1ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1512530-70.2021.8.26.0019 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1512530-70.2021.8.26.0019

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2222663/2021 - DISE- DEL.SEC.AMERICANA, 19660014 - 04º D.P. AMERICANA, 1136/21/350 - DISE- DEL.SEC.AMERICANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABRICIO PELISSARI DE AMORIN

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA

VISTOS.

FABRICIO PELISSARI DE AMORIN foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, 'caput', da Lei 11.343/06, acusado de no dia 16 de agosto de 2021, por volta de 23h18, na Praça da Fraternidade, 100, bairro Jardim da Paz, nesta cidade, trazer com ele 18 porções de cocaína, bem como guardava e mantinha em depósito, outras 48 porções da mesma droga, acondicionadas em Eppendorfs, drogas que determinam dependência física e psíquica, para fins de venda e entrega ao consumo de terceiros, assim o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia foi instruída com Inquérito Policial.

Aplicou-se o rito da Lei 11.343/2006. Manifestaram-se defesa e acusação.

A denúncia foi recebida em 26/10/2021 (fls. 125/126) e o réu foi citado.

Na instrução foram inquiridas duas testemunhas comuns e uma testemunha de Defesa.

Ao final, o réu foi interrogado.

Sem mais requerimentos, nos debates, a acusação requereu a procedência da denúncia,

alegando provados os fatos criminosos, materialidade e autoria. Discorre sobre pena e regime.

A Defesa reclama absolvição por insuficiência probatória. O acusado seria usuário de drogas. A prova seria insuficiente para comprovar tráfico. A praça era conhecida nos meios policiais. Pesava contra o réu apenas a versão dos guardas civis, que não possuíam atribuição para polícia ostensiva ou realizar diligências investigativas. As buscas realizadas seriam ilícitas, sem a necessária justa causa. É o relatório.

DECIDO.

A arguição preliminar de nulidade processual é improcedente.

Semelhante alegação de nulidade é genérica, sem indicação concreta de que, nestes autos, houvesse não observância das normas pelos agentes de autoridade que recomendasse o decreto de nulidade, fosse para desconsideração da prova, fosse para macular a própria ação penal.

O acusado foi submetido a procedimento rotineiro, pelas circunstâncias, autorizado o agente da autoridade a assim revistá-lo, em especial porque havia denúncia antecedente descrevendo as suas características e de que estaria traficando. A abordagem também se justificava pela notícia de que portava e escondia drogas (ao lado da pista), estando nas imediações de ponto de venda de drogas.

Evidentemente, local público, não demandava mandado para buscas no local. E a revista, no réu, era emergente e justificada.

No mérito, é caso de condenação.

Perante a autoridade policial, negou qualquer envolvimento com o tráfico de drogas. É usuário de crack. Havia saído de sua residência, com destino a uma tabacaria situada naquele bairro, onde ingeriu uma lata de cerveja e comeu um pacote de salgadinho. Ao sair da tabacaria, caminhava próximo da Praça do Jardim da Paz, na praça do skate. Procurava por alguém que estivesse vendendo crack, quando foi abordado pelos guardas municipais. Foi agredido pelos agentes, que apertaram os seus testículos, exigiam que apontasse onde estavam as drogas, mas não tinha nada em seu poder, apenas a quantia de R\$ 13,50 (restante do dinheiro após comprar a cerveja e o salgado). Pretendia comprar uma pedra de crack, com o restante do dinheiro. Após ser abordado e revistado, foi algemado e conduzido até a Delegacia por uma viatura, enquanto outra viatura ficou no local procurando drogas. Não presenciou e não viu os entorpecentes que os guardas apresentaram e não sabe dizer a quem as pertenciam (fls. 05/06).

Em juízo alegou que era usuário de drogas, estava no local para comprar entorpecentes. Enquanto esperava o rapaz trazer a pedra de crack, foi abordado. Morava há vinte e um anos naquele local, nunca traficou. Estava há quatro anos na rua, assinava carteirinha. Os processos que respondeu anteriormente foram todos pelo uso de drogas.

Os policiais pisaram nos seus testículos para que falasse onde era a casa do traficante, senão "iria segurar" a droga. Foi torturado, mas não informou os dados do traficante para não ser preso. Seus vizinhos o conhecem e sabem que não traficava. Realizava trabalhos de pintura e pedreiro para os vizinhos, não tinha nem o que comer em sua casa. Não poderia ficar na rua após a meia noite. Tinha um bar na frente da biqueira. Procurou pelo rapaz de bicicleta que ficava na biqueira vendendo drogas para comprar uma pedra de crack, mas ele não tinha com ele e foi buscar. Enquanto esperava ele retornar, foi abordado pelos guardas. Antes, foi encontrar Paulo para pedir dinheiro, tinha bebido em casa. Comprou a bebida com R\$ 5,00 que a vizinha lhe deu. Os R\$ 10,00 que portava era para comprar crack. Tinha solicitado mais R\$ 2,00 para Paulo para comprar um maço de cigarro, que custava R\$ 5,50. Nunca traficou. Os guardas exibiram uma foto no celular do rapaz que vendia drogas e queriam que o levasse até a casa dele. Era usuário de crack desde os dezesseis anos de idade. Já foi internado duas vezes pelo uso de entorpecentes, chegou a ficar em coma. Seus pais são falecidos.

A versão não convence.

A testemunha guarda municipal José Luciano Salvato recordou-se de que estavam em patrulhando pelo bairro Parque da Liberdade, quando foram solicitados por populares. Eles informaram que havia um homem vendendo drogas, próximo da pista de

skate, da Praça da Fraternidade. Os informantes descreveram que o suspeito trajava blusa preta com capuz e calça jeans e que ele escondia os entorpecentes naquelas proximidades. Deslocaram-se até o endereço informado, onde avistaram um rapaz com as características descritas. Ao perceber a aproximação da viatura, observaram o acusado dispensando algo ao solo, que identificaram posteriormente tratar-se de dezoito porções de cocaína, embaladas em microtubos. Diligenciaram nas proximidades da pista de skate, onde localizaram mais quarenta e oito microtubos, idênticos aos que foram dispensados pelo réu. Em revista pessoal, localizaram a quantia de R\$ 13,50 em poder do acusado. Não o surpreenderam no ato de venda. Presenciaram quando o acusado segurava um objeto e o dispensou ao solo. No momento da abordagem, por volta de 23h20, não identificou outras pessoas ao redor da praça. Indagado, o réu negou que estivesse na prática da venda de entorpecentes.

A informação que tinham era a de que o acusado vendia e escondia drogas naquele local. Encontraram o restante das drogas em uma vegetação bem próxima, ao lado da pista de skate, em uma distância menor que dez metros, embaladas de forma idêntica às dispensadas pelo acusado. Conhecia o acusado de abordagens anteriores, mas nunca tinha encontrado nada de ilícito em seu poder. Durante a revista pessoal, não encontraram drogas com o implicado, mas viram ele dispensando. O local era conhecido como ponto de venda de drogas. A denúncia anônima foi feita por populares que abordaram a viatura na rua. Não foi necessário acionar a equipe do canil para encontrar o restante das drogas.

Clóvis Alves de Souza, outro guarda, ratificou a versão em uníssono, harmônica e coerentemente. Patrulhavam pelo bairro Jardim da Paz, quando foram solicitados por populares, os quais informaram que próximo da pista de skate havia um homem traficando e que também escondia drogas ao lado da pista. Descreveram que ele trajava blusa preta de capuz e calça jeans. Deslocaram-se até a pista de skate e avistaram o suspeito, com as mesmas características informadas pelos populares. Ao se aproximarem, avistaram o rapaz dispensando algo no chão. Realizaram a abordagem e durante a busca pessoal localizaram a quantia de R\$ 13,50. Averiguaram o objeto dispensado e encontraram dezoito pinos, que aparentavam ser cocaína. Em buscas realizadas no entorno da pista de skate, localizaram mais dois kits, contendo mais quarenta e oito pinos da mesma substância, idênticas as que haviam sido dispensadas. Indagado, o acusado negou a traficância, alegou que estava só de passagem pelo local. Diante dos fatos, ele foi apresentado no Plantão Policial. Era tarde da noite, não identificaram outras pessoas próximas do acusado no momento da abordagem. O local era conhecido como ponto de tráfico de drogas, já realizaram outras abordagens similares e várias prisões naquele endereço. A droga dispensada e as localizadas escondidas estavam embaladas de forma idêntica. Fabrício não aparentava ser usuário de crack. Ele trajava boas vestimentas, calça, tênis e blusa de frio. A denúncia anônima era proveniente de populares, que pararam a viatura durante o patrulhamento.

A testemunha de Defesa Paulo Edson de Oliveira relatou que conhecia o acusado há aproximadamente dois ou três anos, moravam próximos. Fabrício não era traficante de drogas. Tinha conhecimento de que o acusado estava desempregado e vivia sozinho, ele fazia limpeza terrenos e era benquisto na vizinhança. Presenciou a abordagem e não viu nada em poder de Fabrício no momento da abordagem. Tem conhecimento de que Fabrício era usuário de crack. Os fatos ocorreram por volta de 22h50, estava escuro, mas de onde estava pode ver a abordagem. Tinha um gordinho pelo local. Havia conversado com ele há pouco minutos, o réu disse que havia ganhado R\$ 5,00 da vizinha da frente da casa ele e solicitou mais R\$ 2,00 ou 3,00 para inteirar o dinheiro, ele estava bêbado. Não forneceu nenhum valor do acusado, não tinha no momento. O réu sentou-se no chão e não viu os guardas localizando sacolinha em seu poder. Viu tudo do lado de fora do bar, não se aproximou porque a pista era frequentada por usuários de drogas. Apenas não acompanhou o momento em que o réu foi colocado no chiqueirinho da viatura, pois foi levar um guaraná para sua mulher. A versão não exime o réu de responsabilidade ou menos desprestigia a firme versão de guarda civil.

Os guardas municipais, que tinham o local como ponto de tráfico, receberam denúncia de tráfico, descrevendo ao réu e o endereço onde poderia ser localizado.

O réu, ao visualizar a viatura e suspeitar que seria abordado, jogou os entorpecentes ao solo (18 pinos de cocaína), com fim de se eximir de sua propriedade e responsabilidade. Revistado, com ele foi localizada a importância de R\$ 13,50, sem que o réu, prontamente ou a qualquer tempo, justificassem a lícita procedência.

Em abono disso, próximo de onde estava e conforme a informação recebida, os guardas encontraram o restante das drogas (48 pinos de cocaína) mantidas ocultas, para fins de comercialização.

Enfim se conclui, pela prova testemunhal, quantidade-nocividade da droga e forma de embalagem, acompanhada de numerário (com o réu), que se destinavam mesmo ao tráfico. Idem para o numerário, sem procedência lícita provada, em ponto de tráfico.

O auto de exibição e apreensão confirma a apreensão da droga, na quantidade informada na denúncia.

Trata-se de crime de ação múltipla e conteúdo variado, não carecendo a prática de atos de venda para a configuração do tráfico.

Na doutrina:

"Nota-se facilmente que o crime do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é de ação múltipla, isto é, possui várias condutas típicas separadas pela conjunção alternativa "ou". Em razão disso, a pluralidade de condutas envolvendo o mesmo objeto material constitui crime único. Exemplo: adquirir, transportar, guardar e depois vender a mesma substância entorpecente. Nesse caso, há um só crime, porque as diversas condutas são fases sucessivas de um mesmo ilícito. Os crimes de ação múltipla são também chamados de crimes de conteúdo variado ou de tipo misto alternativo. A prática de qualquer das condutas descritas no art. 33, caput, é suficiente para a caracterização do crime de tráfico ilícito de drogas, sendo desnecessária a realização de atos de venda do entorpecente." (Victor Eduardo Rios Gonçalves, 2020, pág.87, Legislação Penal esquematizada).

E na jurisprudência:

"Para a caracterização do tráfico de entorpecente, irrelevante se torna o fato de que o infrator não foi colhido no próprio ato da venda da mercadoria proibida. Ademais, esse delito é de caráter permanente, consumando-se com a detenção do tóxico pelo agente para comercialização" (RT 714/357).

"Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, 'contrário sensu'), dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente" (RT 584/347).

"ENTORPECENTE - Tráfico - Agente que não comercializou a droga - Caracterização pela simples guarda, pois o tipo do art. 12 da Lei 6.368/76 é de conteúdo variado ou misto alternativo" (TJRS, RT 745/633).

E, por pertinente: "ENTORPECENTE - Tráfico - Caracterização - Crime de perigo abstrato - Desnecessidade da prática de efetivo ato de comércio, bastando que o agente seja apanhado trazendo consigo, guardando ou mantendo em depósito a substância entorpecente, para finalidade de venda. Inteligência do art. 12, caput, da Lei 6.368/76" (TJSP, RT 793/576).

A versão dos guardas municipais, do mesmo modo, é segura e não deve ser desprezada tão só pela condição de agente da autoridade.

É do C. STF: "HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações." (STF HC 87.662-5/PE Rel. Min. Carlos Ayres

Britto j. 05.09.06 DJU 16.02.07);

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF HC 73.518-5 Rel. Min. Celso de Mello DJU 18.10.96, p. 39.846);

O fato do réu também ser usuário de droga e traficar para sustentar o vício, evidentemente, não exonera a conduta, antes tem por absorvido, o porte de drogas para uso, pelo tráfico ora reconhecido.

A materialidade da infração, no tráfico, foi provada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 12), pelo laudo de constatação (fls. 13/15), bem como pelo exame químico toxicológico (fls. 114/116).

Bem típica a conduta, pois, que merece severa punição.

Fixação das penas.

O réu possui Maus antecedentes (Processo nº 0023084-27.2010.8.26.0019 - 2ª Vara Criminal do Foro de Americana/SP, com trânsito em julgado para a Defesa em 15/08/2012; Processo nº 0008975-37.2012.8.26.0019 - 1ª Vara Criminal do Foro de Americana/SP, com trânsito em julgado para a Defesa em 05/07/2013). A pena deverá ser fixada acima do mínimo legal pelos Maus antecedentes do acusado.

Fixo a pena base, pois, com essas considerações, em seis (06) anos de reclusão e seiscentos (600) dias-multa.

Na segunda, não há circunstância a ser considerada, mantendo inalterada a pena base.

Na terceira e última fase, sem comprovação de que se dedicasse a atividades criminosas e nem integrasse organização criminosa, reduzo a pena em 1/3 (um terço), assim a tornando definitiva (4 anos e 400 dias-multa). O percentual se justifica pela nocividade da droga apreendida, bem como pelas circunstâncias judiciais, nada indicando que redução inferior se ajustasse aos propósitos do artigo 33, par. 4º da Lei de Drogas.

É de se impor o regime inicial semiaberto, pela somatória da pena, reclusiva, não se mostrando socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, aqui por que desfavoráveis as circunstâncias judiciais, na fixação da pena.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC nº 111.840/ES, afastou a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados, devendo-se observar, para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena, o disposto no artigo 33, c.c. o artigo 59, ambos do Código Penal.

Depois, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu o entendimento de que: "Esta Corte, na esteira do posicionamento do Supremo Tribunal Federal, entende ser possível nas condenações por tráfico de drogas, em tese, a fixação de regime menos gravoso, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, sempre tendo em conta as particularidades do caso concreto." HC nº 239.999/MS, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 21.08.2014.

Na mesma evolução, com a promulgação da Lei nº 13.964/2019 (popularmente conhecida como "pacote anticrime"), houve necessidade de maior reflexão pelos julgadores. Dentre as alterações previstas no regime legal, houve alteração expressa da Lei de Execuções Penais, em especial no tocante ao "tráfico privilegiado": Lei de Execuções Penais: Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019). (...) § 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.

"...Todavia, evidenciadas as peculiaridades do caso concreto, não se impõe a

referida substituição, uma vez que a culpabilidade exacerbada do apelante não autoriza essa benesse (cf. artigo 44, inciso III, do Código Penal), sendo certo que a pena privativa de liberdade revela-se a única resposta penal efetivamente apta a atender ao requisito preventivo-retributivo da reprimenda, na medida em que repreende agente que cometeu grave crime de tráfico de drogas, ainda que privilegiado, não se afigurando socialmente recomendável, portanto, a referida substituição." Apelação Criminal nº 1500108-35.2019.8.26.0536, sessão permanente e virtual da 15ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 14 de outubro de 2020. RICARDO SALE JÚNIOR Relato

No C. STJ:

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na definição do modo inicial de cumprimento de pena, necessário à prevenção e à reparação da infração penal, o magistrado deve expor motivadamente sua escolha, atento às diretrizes do art. 33 do Código Penal e, na hipótese de condenado pelo crime de tráfico de drogas, ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual serão consideradas com preponderância a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. 2. Inobstante a pena definitiva tenha sido fixada em 2 anos e 6 meses de reclusão e o recorrente seja primário, o regime semiaberto é o cabível à espécie (como o imediatamente mais grave, segundo o quantum da sanção aplicada), em decorrência da valoração negativa da quantidade e da natureza da droga apreendida na terceira fase da dosimetria (28,2 gramas de cocaína e 138,4 gramas de maconha). 3. Não sendo possível se vislumbrar a ocorrência de ilegalidade flagrante ou de constrangimento ilegal, resta descabida a concessão de habeas corpus, de ofício. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1584206/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS E no E. TJSP:

"APELAÇÃO. Tráfico de entorpecentes. Recurso ministerial. Pleito de afastamento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06. Impossibilidade. Primariedade do réu e quantidade de drogas que não se mostra excessiva. Inexistência de prova nos autos de que o apelado se dedique a atividades criminosas ou de que pertença a organização voltada à prática de delitos. Regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda que não comporta reparos. Negado provimento ao recurso" (TJSP Apelação nº 1518025-21.2019.8.26.0228 / Diadema / SP, Rel. Leme Garcia, 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, julgado em 09 de março de 2020).

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, a ação penal que a JUSTIÇA PÚBLICA promoveu para condenar a FABRICIO PELISSARI DE AMORIN, às penas de quatro (04) anos de reclusão, regime inicial semiaberto e quatrocentos (400) dias-multa, piso, por infração ao artigo 33, 'caput' e parágrafo 4º, ambos da Lei número 11.343/2006.

Não há valor mínimo indenizatório a ser arbitrado.

Isento o réu das custas, assistido por defensor nomeado e presumida a necessidade (fls. 61).

Vinculado o numerário apreendido com o crime cometido, decreto a sua perda em favor da União, bem como eventuais objetos apreendidos, ficando autorizado, quanto a estes últimos, doação ou destruição, acaso inservíveis ou sem valor econômico, o que será certificado.

Certifique-se quanto à destruição da droga.

Após o trânsito, inscreva-se o nome do réu no rol dos culpados.

Faculto recurso em liberdade, porque assim o réu vem respondendo aos atos do processo.

P.I.C.

Americana, 31 de janeiro de 2022.

ANDRÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA